



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

1 פאילייב יצחק, ת.ז. 307513101 התובעים  
(הנתבעים שכנגד):

2 מירזייב שרה, ת.ז. 307513192

באמצעות ב"כ עו"ד רונן גולן

-נגד-

1 אוחיון איתאל יעקב, ת.ז. 200317907 הנתבעים  
(התובעים שכנגד):

2 אוחיון ברוריה, ת.ז. 305578940

באמצעות ב"כ עו"ד עוז כהן

## פ ס ק - ד י ן

עניינו של פסק דין זה בטענות בדבר השתלטות על רכוש משותף ובנייה שלא כדין.

### רקע

1. הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 30645 חלקה 3 הממוקם ברחוב שד' נווה יעקב 70, ירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**). הבית המשותף כולל 32 דירות ומורכב ממבנה בן 3 קומות. הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים וחל עליו תקנון מוסכם.

2. התובעים (להלן גם: **"פלאייב"**) הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 4 אשר שטחה הרשום הוא 67.1 מ"ר ולה 13/396 חלקים ברכוש המשותף ללא הצמדות מסוימות (להלן: **"דירת התובעים"** או **"דירת פלאייב"**). דירת התובעים ממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף. הנתבעים (להלן גם: **"אוחיון"**) הם בעליה של הדירה הידועה כתת חלקה 3, שטחה הרשום הוא 88.50 מ"ר ולה 12/396 חלקים ברכוש המשותף (להלן: **"דירת הנתבעים"** או **"דירת אוחיון"**). דירת הנתבעים שוכנת גם היא בקומת הקרקע של הבית המשותף וגם לה לא רשומות הצמדות כלשהן. דירות הצדדים ממקומות בסמיכות זו לזו, כאשר מפלס דירת אוחיון גבוה במעט ממפלס דירת פלאייב. יש לציין עוד כי שתי הדירות הורחבו במהלך השנים ושטחם הנוכחי רחב מן השטח הרשום במרשם המקרקעין.

3. בדירת התובעים בוצעה לפני שנים מספר הרחבה לכיוון מזרח באופן בו הורחב חדר קיים כאשר מהצד הדרומי של אותה ההרחבה נפער חלון (ראה סימון החלון בנספח ה' לתצהיר התובע 1 מיום 18.2.18, להלן: **"החלון"** או: **"החלון בדירת פלאייב"**). יש לציין כי בשלוש דירות נוספות הממוקמות מעל דירת פלאייב בוצעה הרחבה דומה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואף נפערו חלונות לצד הדרומי בממדים זהים (כפי שניתן היה להבחין בביקור שערכתי במקום מיום 1.5.19). תביעה זו הוגשה עת הנתבעים ביקשו להרחיב את דירתם באופן בו תיבנה, בין היתר, מרפסת בצד המזרחי של דירתם, בסמוך לחלון בדירת פלאייב וזאת בהתאם להיתר מס' 0358.02/2007 (נספח יא' לתצהיר הנתבע 1, להלן **"ההיתר"** או **"היתר הבנייה"**).

4. בתביעתם טענו פלאייב כי אוחיון מבצעים עבודות בנייה ברכוש המשותף הכוללות חפירה לשם בניית מחסן מתחת לדירתם וכן מתעתדים לבנות מרפסת מול החלון באופן שיחסום את כניסת האור והאוויר לדירתם ויפגע בפרטיותם. בתביעה נטען כי הנתבעים החלו זה מכבר בעבודות הבנייה, בהתאם להיתר בנייה שפג תוקפו ומבלי שהם אוחזים בהסכמת יתר בעלי הדירות. בתביעתם עתרו לסעדים הבאים:

**"ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות המרפסת שעתידיה לחסום ולאטום את חלון התובעים או לחלופין ליתן צו הצהרתי הקובע כי המרפסת נבנתה שלא כדין ודינה להיהרס.**

**כמו כן, ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לחפור ולבנות את המחסן מתחת לדירתם וזאת בהעדר הסכמות כנדרש לפי חוק המקרקעין, או לחלופין ליתן צו הצהרתי הקובע כי המחסן נבנה שלא כדין ודינו להיהרס.**

**לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד."**

5. במקביל להגשת התביעה עתרו פלאייב לקבלת צו מניעה זמני האוסר על אוחיון את בניית המרפסת מול חלון דירת התובעים (בחזית המזרחית של הבית המשותף) וכן אוסר עליהם לבצע עבודות בניה כלשהי ברכוש המשותף. דיון בצו המניעה התקיים ביום 26.6.17, במהלכו טען ב"כ פלאייב דאז כי **"אנחנו מוכנים לצמצם את צו המניעה בצורה כזאת שרק המרפסת לא תיבנה"**. לפיכך, ניתנה החלטה לפיה: **".. תצומצם הבקשה לצו מניעה אך לנושא בניית המרפסת, ובנושא זה בלבד יתקיים המשך הדיון בבקשה לצו המניעה"**. בהחלטה מיום 29.6.17 נקבע, בתמצית, כי סיכויי התביעה לא הוכחו די הצורך ברמה הלכאורית שכן בשלב הבקשה הציגו המשיבים ראיות לכאוריות להסכמת 3/4 מבעלי הדירות כדין, וכך לא עלה בידי המבקשים ברמה הלכאורית להצביע על פגיעה מהותית בדירתם (בשים לב לעובדה כי התברר שבסמוך לאותו חלון ממוקמת ויטרינה רחבה המכניסה אור ואוויר לדירתם). כמו כן, נקבע, בין היתר, כי חל שיהוי של ממש בהגשת הבקשה שעה שזו הוגשה לאחר שעבודות הבניה כבר החלו והקירות החיצוניים בדירת אוחיון נותרו פעורים לצורך הבניה. עוד צוין כי על אף שבקשת ההיתר הייתה צריכה להיות ידועה לפלאייב אלו לא הגישו בגינה כל התנגדות. במכלול נסיבות אלו נדחתה הבקשה לצו מניעה זמני, תוך שהודגש כי **"... אין באמור לעיל בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ביחס לתביעה העיקרית ולא מן הנמנע כי לאחר שישמעו עדים נוספים ויוגשו ראיות נוספות, תתהפך הקערה על פיה. בהקשר זה אעיר כי אם ייבחרו המשיבים להמשיך בבניית ההרחבה המבוקשת הרי שעליהם להיות מודעים לכך שההחלטה דנן עוסקת בסעד זמני בלבד, וכי לו יימצא, בסיומו של ההליך, כי דווקא ידם של המבקשים על העליונה, יכול ויהא על המשיבים להרוס את בניית ההרחבה המבוקשת ולהחזיר את המצב לקדמותו. על כן מוטב לו ישקלו המשיבים האם, על אף היעדר צו מניעה, יהיה זה נכון מבחינתם להמשיך בבנייה בשלב זה, טרם ההכרעה הסופית בהליך..."**.

6. בסופו של יום, תוך כדי ניהול ההליכים השלימו אוחיון את בניית המרפסת והמחסן.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. הנתבעים, מצדם, הגישו כתב תביעה שכנגד במסגרתו טענו אף הם להשתלטות ובנייה שלא כדין שביצעו פלאייב ברכוש המשותף. בין היתר, נטען כי דירת פלאייב הורחבה לכיוון המסד תוך השתלטות על חללים ופגיעה ברכוש המשותף, כי פלאייב השתלטו על חדר המדרגות והמקלט והניחו שם את חפציהם האישיים. עוד נטען כי השתלטו על חצר וסגורה באופן המונע מעובדי חברת הגיחון לקרוא את מוני המים והגז.

8. במסגרת התביעה שכנגד, עתרו אוחיון לסעדים הבאים:

**"להורות לנתבעים, ביחד ולחוד, לאפשר כניסה חופשית לשטח גינתם על מנת לגשת למוני המים והגז, על ידי עובדי הגיחון וחברת הגז ולהסיר את המנעול והקודן מכניסת דלת החצר.**

**להורות לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק ידם מקומת המסד והחללים שמתחת לדירתם ולהשיב את המצב לקדמותו. להורות לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק ולפנות את החפצים והמיטלטלין השייכים להם בחדר המדרגות ובמקלט הבית המשותף.**

**להורות על הסרת מנוע המזגן החוסם את פתח המילוט ולהניחו במקום שאינו מפריע לתובעים.**

**להורות לנתבעים לאטום את החלון אשר פרצו בקיר הבית המשותף בניגוד להיתר הבנייה שלא כדין, כאמור לעיל והפונה למרפסת דירת התובעים שהורחבה לאחרונה.**

**ליתן צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבעים, לבצע כל בנייה ברכוש המשותף וכל השתלטות ברכוש המשותף וכן להפריע לשימוש רגיל וסביר של התובעים בכל שטחי הרכוש המשותף.**

9. לתקופת מה המשיך בירור הליכים אלו לפני המפקח א. סילברמן (כתוארו דאז) בפניו התקיימו דיונים מקדמיים בימים 29.11.17, ו- 7.6.18 וכן נערך על ידו ביקור במקום ביום 12.12.17 בנוכחות הצדדים. התיק הועבר לטיפול לאחר פרישתו של המפקח סילברמן מתפקיד זה (דצמבר 2018) ודיון הוכחות התקיים לפניי ביום 1.5.19. כעולה מפרוטוקולי הדיון, המותב הקודם אשר דן בהליך העלה לפני הצדדים הצעות לסיום הדיון בהסכמה וכך גם עשה המותב הנוכחי, אולם למרבה הצער ללא הואיל. בסיום דיון ההוכחות, ביום 1.5.19, ערכתי, בנוכחות הצדדים, ביקור במקום. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להבנות, הגישו הצדדים סיכומי טענותיהם בכתב.

### **עיקרי טענות פלאייב- תיק 241/17**

10. לטענת התובעים, הנתבעים ביצעו עבודות בנייה ברכוש המשותף ללא היתר בתוקף וללא הסכמת בעלי הדירות כדין. נטען כי באופן זה נבנה מחסן מתחת לדירתם בשטח הרכוש המשותף וכך גם נבנתה מרפסת בחזית המזרחית. נטען כי בניית המרפסת חוסמת את חלון דירתם, באופן שבו נגרמת לדירתם פגיעה מהותית שכן החדר חשוך, אפל, מחניק, ללא אור ואוויר, דבר הפוגע גם בערך הדירה. עוד נטען כי היות שהמרפסת נבנתה בגובה שמעל לדירת פלאייב היא גם מהווה פגיעה קשה בפרטיותם.

11. באשר למחסן, נטען כי הנתבעים מבצעים את הבניה בניגוד לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 מבלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות לכך. נטען כי אוחיון חפרו לעומק רב יותר מהמותר לפי היתר הבנייה שמצוי בידם והפכו אותו למחסן על חשבון החצר המשותפת.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. באשר לסוגית ההסכמות נטען כי מראש, טרם הבנייה, לא אחזו אוחיון בהסכמות בעלי הדירות כנדרש ואילו רק לאחר שניתן צו המניעה פנו בבקשה לקבלת את ההסכמות הנדרשות. לפיכך נטען כי ההסכמות שניתנו, אם וככל שניתנו, ניתנו רק בדיעבד. נטען כי חלק מחתימות בעלי הדירות כפי שהוגשו נחזים להיראות ככאלה שנחתמו באותו כתב יד וספק אם נחתמו על ידי מי שנטען שחתמו.

13. עוד טוענים פלאייב כי לצורך מימוש הבניה שביצעו הנתבעים נדרשת חתימת כל בעלי הדירות בהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. לטענתם, אף אם במקרה הנדון חל החריג הקבוע בסעיף 71ב לחוק זה, לא הוכיחו הנתבעים כי יש בידם הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, היינו 24 דירות להם צמודים 264/396 חלקים. נטען כי בדיקת נסח הרישום אל מול כתבי ההסכמה מעלה כי בבית המשותף 13 בעלי דירות שלא נתנו הסכמתם. נטען כי התובעים הציגו חתימות של בעלי דירות אשר חזרו בהם מההסכמה שנתנו לאוחיון וכי יש לקבל את חזרתם מהסכמתם בשים לב לכך שהחתימות התקבלו בעיצומו של ההליך, ועל כן אוחיון לא הסתמכו עליהן ולא שינו מצבם בעקבותיהן.

14. פלאייב מוסיפים וטוענים כי אוחיון לא הציגו חתימות על התשריט או בקשת ההיתר, וממילא בנו תוך חריגה מהתוכנית וההיתר ועל כן אף אם היו הסכמות הרי שתוקפן פקע עם ביצוע החריגות שכן הסכמה עצמה מוגבלת ל"תכנית ולהיתר". נטען כי מכל מקום מדובר ב"הסכמה תכנונית" אשר אין בה כדי לוותר על זכויות קנייניות וזכויות בנייה. נטען כי הנתבעים בנו את דלת המרפסת מצדה השמאלי ולא בצדה הימני כפי שמופיע בהיתר הבניה, פתחו חלון רחב עד לרצפה והפכו אותו לדלת יציאה למרפסת, בנו עמוד רחב מתחת למרפסת כאשר לפי ההיתר מדובר במרפסת זיזית ללא עמוד ואף הוסיפו חלון נוסף שאינו מצוין בהיתר הבניה.

15. מכל מקום נטען כי נוכח הפגיעה המהותית בדירת פלאייב, אף אם יימצא שיש בידי אוחיון את ההסכמות הנדרשות כדין, יש מקום להפעלת סמכות המפקחת לפי סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 ולהורות על שינוי ההחלטה ותיקון הפגיעה המהותית הנגרמת לתובעים ועל התאמת כל הבנוי להיתר הבניה אשר לגביו ניתנו ההסכמות.

**ג. עיקרי טענות אוחיון - תיק 241/17, תיק 357/17**

16. אוחיון טוענים כי קיבלו היתר בניה כדין והחלו בבנייה בהתאם לו. נטען כי חלון דירת פלאייב נבנה שלא כדין וללא היתר. נטען כי התביעה מבוססת על חסימת חלון שכלל לא היה צריך להיבנות, כך שמדובר במקרה מובהק בו דינה של התביעה להידחות מכל הכלל ליו "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה". מכל מקום נטען כי המרפסת רחוקה מרחק של 1.5 מ' מחלון דירת פלאייב.

17. אוחיון טוענים כי טענת פלאייב ל"פגיעה מהותית" בדירתם בדמות של מניעת כניסת אור ושמש כלל לא הועלתה בתביעתם וכי ממילא המפקחת אינה מוסכמת לדון בעילות נזיקיות של מטרד. מכל מקום נטען כי בחזית מרפסת דירת פלאייב קיימת ויטרינה המכניסה אור ואוויר ולכן אין ממש בטענתם כי המרפסת היא החוסמת כניסת אור ואוויר. עוד נטען כי התובעים עצמם התקינו פרגולה בסמוך לוויטרינה, עובדה הסותרת את טענתם לחסימת אור ואוויר.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. נטען כי המפקח נעדר סמכות לדון בטענות תכנוניות וכי מכל מקום היות שהעבודות החלו באותה שנה בו ניתן היתר הבנייה הרי שבעת בניית המרפסת היה ההיתר בתוקף.
19. אוחיון מוסיפים וטוענים כי על אף שפלאייב ידעו על כוונת אוחיון לממש את היתר הבנייה ישבו בחיבוק ידיים דבר המלמד על השיהוי הגדול שנפל בהגשת התביעה.
20. לטענת אוחיון, פלאייב הרחיבו זה מכבר את דירתם ובנוסף ביצעו בנייה שלא כדין על דרך הוספת חדרים מתחת לדירתם. כמו כן, סיפחו שלא כדין לדירתם שטח חצר מהרכוש המשותף. לפיכך, נטען כי ביצעו "הרחבה דומה" ולפיכך מנועים מלהתנגד להרחבה שביצעו אוחיון.
21. מוסיפים אוחיון וטוענים כי לשם ביצוע עבודות הבנייה לפי היתר הבנייה קיבלו את ההסכמות הדרושות כדין של 3/4 מבין בעלי הדירות. נטען כי הסכמות אלו לא נסרתו וכי טענת הזיוף הועלתה לראשונה בסיכומי התובעים תוך הרחבת חזית אסורה. נטען כי פלאייב לא ביקשו לחקור את מי שלטענתם חתימתו זויפה ולא הביאו ראיה כלשהי להוכחת הטענה. נטען כי אין כדין כל חובה לכינוסה של אסיפה כללית טרם קבלת ההסכמות ואף פלאייב לא עשו כן טרם שהרחיבו את דירתם שלהם. בהקשר לנושא ההסכמות נטען עוד כי חתימת בן זוג אחד מחייבת גם את האחר וכי לא נדרשת חתימת שני בני הזוג בעלי הדירה.
22. בסיכומיהם טוענים אוחיון כי כל מסמכי "החזרה מההסכמה" ניתנו לאחר שהמרפסת כבר נבנתה והנתבעים שינוי מצבם לרעה בהסתמך על ההסכמות. באשר לטענה כי ההסכמה הייתה אך למותר לפי היתר הבנייה ולא לביצוע בפועל אשר חרג ממנה, נטען כי ההסכמות הן "קנייניות" ואינן תכנוניות.
23. נטען כי המחסן נבנה כדין כחלק מהיתר הבנייה ואינו משמש לקבלת לקוחות כנטען.
24. באשר לתביעה שכנגד טוענים אוחיון כי פלאייב הם פורעי חוק אשר השתלטות על רכוש משותף, סיפחו את חצר הבית המשותף, חסמו את פתח המילוט באמצעות מזגן, פלשו אל קומת המסד והרחיבו את דירתם לעברה, השתלטו על חדר המדרגות והניחו בו חפצים שונים ואף אינן משלמים את דמי הניהול וההחזקה. נטען כי בנסיבות אלו הגשת התביעה על ידם בעניין המרפסת נגועה בחוסר תום לב קיצוני.
25. לטענת אוחיון, החלון בדירת פלאייב אינו חלק מההיתר המקורי של דירת פלאייב, הוא איננו חוקי ודינו להיסגר. נטען כי הוא נבנה ללא היתר בנייה. לטענתם בעת שרכשו את דירתם הסתמכו על היתר בנייה שמלמד כי אין חלון בדירת פלאייב הפונה אל עבר מרפסת דירת הנתבעים.
26. עוד נטען כי פלאייב פלשו אל קומת המסד של הבית המשותף והרחיבו דירתם ללא היתר ושלא כדין. נטען כי הוכח שכבר ניסו להשתלט על אותו שטח ולהכשירו (תיק פלילי שנפתח בביהמ"ש לעניינים מקומיים 6292/04) כך שהדבר מצדיק מתן צו מניעה קבוע. נטען כי טענת פלאייב שבעלי הדירות השכנים נתנו הסכמתם לשימוש זה לא הוכחה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. נטען כי התקנת המזגן כפי שביצעו פלאייב, במעבר לפתח החירום, נעשתה ללא הסכמות כדין תוך הפרעה למעבר חופשי מפתח החירום של המקלט.

**ד. עיקרי טענות פלאייב בתביעה שכנגד- 357/17**

28. פלאייב טוענים כי יש לדחות את התביעה שכנגד מחמת חוסר תום לב, מניעות והשתק. נטען כי אוחיון לא יכולים לעשות שימוש משך שנים בתוספת בלתי חוקית כמו גם להשתמש באופן ייחודי ברכוש משותף ומנגד להעלות טענות כנגדם.

29. לטענת פלאייב, חלים על אוחיון כללי ההשתק שעה שרכשו את דירתם עת היה קיים חלון בדירת פלאייב הפונה לעבר דירתם ועל כן יש לראותם כמסכימים לקיומו.

30. נטען כי החלון מהווה חלק מעמודה שלמה שהוכשרה בהתאם להיתר כדין כאשר כל בעלי הדירות באותה עמודה פתחו את אותו חלון ומראה הצד החיצוני של העמודה הוא מראה אחיד הכולל חלונות אחידים. נטען עוד כי החלון גם נמצא במסגרת תנאי ההיתר.

31. פלאייב מוסיפים וטוענים כי יש לדחות את הסעד הנוגע לסגירת החלון שכן כל טענות אוחיון בהקשר זה נוגעות להיתר בנייה ולא נטענה כל פגיעה קניינית. לטענת פלאייב פתיחת חלון היא שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. מכל מקום רוב הדיירים פתחו או הרחיבו חלון וגם מטעם זה, בהתאם לסעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, יש לראות בפלאייב כמי שבידם ההסכמה הדרושה לפתיחת חלון.

32. בכל הנוגע לטענות אחרות שעלו בנושא השתלטות על החדר בקומת המסד ועל החללים שם, נטען כי מדובר בטענות חסרות בסיס. נטען כי בהתאם להכרעת הדין בב"ש 6292/04 לא נשללו השימוש והגישה לקומה התחתונה בדירת פלאייב וכל שנדרש הוא חסימת החלונות כפי שאכן נעשה. נטען כי פלאייב רכשו דירתם באופן בו היא קיימת, כך שהחדר בקומת המסד קיים שם מזה כשלושים שנה. נטען כי ניתנה הסכמת השכנים לשימוש בחדר בקומת המסד וכי אף אחד מבעלי הדירות לא מחה על כך. עוד נטען שבמפלס התחתון קיים חלל סגור שלא נעשה בו כל שימוש.

33. מכל מקום נטען כי אוחיון מנועים מלהעלות טענה זו לפי סעיף 71ב (ג) לחוק נוכח קיומה של "הרחבה דומה", לאור הבניה שביצעו הם עצמם ברכוש המשותף, ובשים לב גם לבניה שביצעו בעלי דירות אחרים.

34. נטען כי פלאייב לא עושים כל שימוש בחדר המדרגות. באשר למקלט נטען כי אין לפלאייב כל דבר במקלט המשותף ודווקא אוחיון הם שהשתלטו עליו שלא כדין והניחו בו חפצים.

35. לגבי הגישה לשעוני המים והגז נטען כי שעוני אוחיון כלל לא נמצאים בחצר שבשימוש פלאייב ולכן ממילא לא נמנעת מהם הגישה לשעונים. כמו כן נטען כי שער החצר של פלאייב פתוח ולא נעול ואין כל מגבלה מלהיכנס אליו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. בעניין מנוע המזגן נטען כי הוא מותקן במרחק שני מטרים מפתח היציאה ואינו מהווה מחסום או מכשול. התקנתו מהווה שימוש סביר ברכוש משותף. נטען כי הנתבעים עצמם התקינו מנוע מזגן בסמוך למקלט.

### ה. דיון והכרעה

37. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") – "... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

38. במסגרת תיקון 18 לחוק (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629), ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראת סעיף 62 לחוק כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת וזאת על מנת למצוא בעיות לצפיפות המגורים (ראה בהקשר זה דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114)), לפיכך, חוקקה הוראת סעיף 71ב לחוק הקובעת כך:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

39. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (ר': א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 223- להלן: "אייזנשטיין"), נאמר כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש". בהקשר זה נפסק זה מכבר כי תנאי לקיומה של הרחבה כהגדרת המונח בסעיף 71א לחוק הוא כי הצמדת החלק המסוים ברכוש המשותף צריך להיות בסמיכות פיזית לדירה המקורית (ע"א 1462/10 דוד עטיה נ' ליאור שגיא, פורסם ב"נבו", 2.8.12- להלן: "פרשת עטיה").

40. עם זאת, קבע המחוקק הסדרים פרטניים הנוגעים לבעל דירה שנפגע מקבלת החלטה שעניינה בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה - "פגיעה מהותית" - וזאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים וכן על תשלום דמי איזון לנפגע (ראה בסעיף 71ג(ד) לחוק).

41. "פגיעה מהותית" במובנו של סעיף 71ג לחוק, הוגדרה כ- פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**מטרד מתמשך וכיו"ב...** (ראה אייזנשטיין, עמ' 218. ראה והשווה גם: ע"א (מחוזי-ת"א) 133/97, יוסוביץ נ' חי (פורסם ב"נבו", 3.10.99).

42. במסגרת בחינת רף ההסכמות הנדרש על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71(ב)(ג) לחוק כי - **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**. היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה. פרשנות המושג **"הרחבה דומה"** משמעה – הרחבה מסוג דומה; הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי (ר' גם ע"א (מחוזי י-ם) 3235/02 **אביב דוד נ' גדולטר-בכבוד רונית** (פורסם בנבו, 2.3.03). כך גם נקבע כי יש לתת את הדעת לפרופורציה שבין שטחי ההרחבה (ראה אייזנשטיין, עמ' 234), אם כי השטח איננו קריטריון בלעדי. בהקשר זה נקבע כי: **"יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה"** (ע"א (מחוזי חיפה) 22123-10-10 **זינגר ואח' נ' חדד ואח'**, 14.3.11, (ההדגשה אינה במקור י.ע.ש).

43. באשר לאופן מתן ההסכמה הנדרשת במסגרת סעיף 71 לחוק נקבע זה מכבר שאין צורך שההסכמה תינתן במסגרת האסיפה הכללית. בעניין אזרד (ע"א (ירושלים) 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01 - להלן **"פרשת אזרד"**) ובת"א (שלום-י-ם) 2998/04 **כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי**, תק-של 2005(3), 1595, 1596 מפיו של כב' השופט נעם סולברג, נקבע כי לשון סעיף 71 לחוק מלמדת כי המחוקק לא דרש כינוס אסיפה, להבדיל ממקרים אחרים בחוק בהם דרש את הצורך בה מפורשות - כך למשל בסעיף 159 לחוק בנושא הסכמה למעלית (בהקשר זה ראה גם אייזנשטיין, עמ' 215).

44. נקבע עוד, כי הסכמה זו יכולה להינתן בכל עת, אף לאחר שההרחבה כבר בוצעה, ולא יהא מקום למתן צו האוסר שימוש בהרחבה (מהפן הקנייני כמובן), אם יוכיח בעל הדירה כי בידיו ההסכמות הנדרשות (ראה בהקשר זה מ. דויטש, **קניין**, 698-699 והאסמכתאות שם).

45. על רקע המסגרת המשפטית המפורטת לעיל אבחן להלן את נסיבות המקרה הנדון. אפתח בבחינת התביעה העיקרית ולאחר מכן אדון בתביעה שכנגד. כבר אתה אציין כי דין התביעה והתביעה שכנגד להתקבל באופן חלקי.

### התביעה העיקרית

#### המרפסת

46. ראשית יש לבחון האם לשם ביצוע ההרחבה בדמות של בניית מרפסת בצד המזרחי של דירת אוחיון (להלן: **"המרפסת"**) התקבלה הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש. היות שמרפסת הוכרה כ"הרחבת דירה" (ראה פרשת אזרד לעיל) די ברוב של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, כאשר כעולה מהרקע המשפטי לעיל אין חובה כי הסכמה כזו תינתן במסגרת האסיפה הכללית והיא יכולה להינתן גם בדיעבד. ככל



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהתשובה לשאלה זו תהיה חיובית, יש להמשיך ולבחון האם היא מסבה פגיעה מהותית לדירת פלאייב. עוד יש לבחון בהקשר זה האם יש לראות בהרחבה של המרפסת כ"הרחבה דומה" לזו שבוצעה בדירת פלאייב באופן המונע מפלאייב להתנגד לבנייתה.

47. אוחיון הגישו (נספחים ט' ו-י' לתצהיר עדות ראשית של הנתבע 1) הסכמות בעלי דירות בנוסח הבא:

**"הצהרה והסכמה ברכוש המשותף"**

**אנו הח"מ נותנים בזאת את הסכמתנו להרחבת הבניה בהתאם לתשריט ולתוכנית שהוצגה בפנינו ע"י ה"ה אוחיון איתאל וברוריה מרח' שד' נווה יעקב 18 בנווה יעקב בירושלים, הידוע כגוש 30645 חלקה 3 להרחבת דירה ובניית מרפסת וגידור החצר. אנו מצהירים כי ראינו את תכנית הבניה ואין לנו התנגדות לביצוע הבניה עפ"י התכנית ואנו מסכימים לכך".**

48. על גבי הסכמה זו נחזים להיות חתומים בעלי 24/32 דירות, היינו 75% מבין בעלי הדירות שלהם צמוד 2/3 מהרכוש המשותף. עם זאת יש לבחון את טענת אוחיון כי בפועל 13 מתוך 32 דירות לא נתנו את הסכמתם כדין, אם בשל העובדה כי בעליהם לא חתמו כלל על ההסכמה, או כי חתמו רק חלק בבעלי הזכויות בדירה ואם בשל העובדה כי חזרו בהם מהסכמתם. בסיכומיהם מפנים אוחיון לתתי החלקות הבאות בטענה כי לא נתנו הסכמה או שאין לראות בהסכמתם כהסכמה כדין מטעמים אלו: 1,11, ו-31, 2,4,5,7,9,14,16,22,24, ו-30.

49. טרם שאבחן את הטענות ביחס לדירות המפורטות לעיל אציין כבר עתה כי יש לדחות את טענות פלאייב כי חלק מהחתימות נחזות להיראות מזויפות. ככלל, מקום בו מבקש בעל דירה לבצע הרחבה על הרכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח כי באמתחתו ההסכמה הנדרשת בחוק. העברת הנטל על כתפי הנתבע, בניגוד לכלל, נובעת מייחודיותה של ההוראה הקבועה בסעיף 71 לחוק, המתירה לרוב מיוחד לפגוע בקנייננו של המיעוט (ר' א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק ג', 211-213). זה גם הטעם לכך שעל מבקש ההרחבה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת, והוא לא יוכל לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת. יחד עם זאת, מבקש ההרחבה יצא ידי חובתו, בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת כאמור, וככל שהציג מסמך כזה, הנטל להפריך את ההסכמה חוזר לכתפי הטוען כי אין מדובר בהסכמות כדין (ראה בהקשר זה גם עש"א (י-ם) 44078-10-12 **כובאני ואח' נ' לוין ואח'** (לא פורסם. ניתן ביום 19.12.13)).

50. אוחיון הגישו הסכמות של בעלי הדירות ברף הנחזה להיות זה הנדרש. ככל שלטענת פלאייב מדובר בחתימות שאינן מקוריות או מזויפות, היה עליהם להוכיח זאת. פלאייב לא זימנו לעדות אף אחד מאלו שחתימתם זויפה לטענתם. למעט אמירה בעלמא של "זיוף" או "ספק לגבי זהות החותם" לא ביססו טענה זו בכל ראייה. אי לכך, יש לדחות טענתם זו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. פלאייב טענו כי קיימות 13 דירות שלא ניתנה הסכמתם או שהסכמתם אינה כדין (ראה סעיף 7 לסיכומיהם) מכאן יש ללמוד כי אין חולק שהסכמת 19 דירות אכן קיימת. אי לכך, די בהסכמה של עוד 5 דירות על מנת שאוחריו יאחזו ברף הנדרש בדיון (בכפוף לכך שמתקיים גם התנאי הנוגע לכך ש2/4 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם).

52. באשר לתתי חלקות 2,5,7,14 ו-22 נטען כי ניתנה הסכמה רק של אחד מבני הזוג הרשומים כבעלי הדירות. במקרה של בני זוג, וככל שמדובר בקבלת החלטות בעניין הבית המשותף, לרבות החלטה בדבר הצמדת חלק מהרכוש המשותף לאחת הדירות, הרי שחזקה על בעל דירה שחתימתו ניתנה על דעתו של בן הזוג, אשר הסמיכו בעל פה לייצגו. מכל מקום, צד ג', במקרה זה הנתבעים, יכלו להניח, על פי שתיקתו של בן הזוג אשר לא חתם, כי בן זוגו שחתם הוא שלוחו (ראה סעיף 3 לחוק השליחות וכן ע"א 3563/92, עזבון המנוח מאיר גרטלר ז"ל נ' דבורה גרטלר, פ"ד מח (5) 489). אי לכך דין הטענה להידחות.

53. לתצהירו של התובע 1 צורפו תצהירים של שישה אנשים (נספח יא' לתצהירו) המצהירים כי: **"אני הח"מ... חוזר בי מהסכמתי להרחבת הבנייה .... שבוצעה ע"י ה"ה אוחריו איתאל וברוריה.... הנני מתנגד להרחבת הדירה, בניית מרפסת וגידור בחצר שביצעו אוחריו ואני חוזר בי מהסכמתי לאחר שראיתי את הבניה בפועל שביצעו אוחריו..."** (ההדגשות אינן במקור).

54. למעשה מנוסח החזרה מההסכמה עולה כי זו ניתנה רק לאחר השלמת הבנייה שכן מצוין מפורשות **"לאחר שראיתי את הבניה בפועל..."** מחקירת הנתבע 1 עלה כי ההסכמות שצרף לתצהיר עדותו הראשית ניתנו בחודש יוני 2017, לאחר שהחל בבנייה אך טרם השלים אותה. יש לציין כי הסכמות אלו צורפו גם לתגובת הנתבעים לבקשה לקבלת צו מניעה זמני מיום 22.6.17 (ראה נספח ז' לתגובה זו) וניתן להם משקל לצורך מתן החלטה אשר בסופו של דבר דחתה את הבקשה לצו מניעה ואפשרה את המשך העבודות (ראה למשל האמור בהחלטה זו מיום 29.6.17, בפסקה 38). במצב דברים זה, אין רשאים בעלי הדירות אשר נתנו הסכמתם לחזור בהם ממנה לאחר שהבנייה הושלמה. היות שההסכמה ניתנה בשלבי הביצוע, הנתבעים הסתמכו עליה תוך שינוי מצבם לרעה, אין באפשרותם לחזור בהם בשלב בו עשו כן. יתרה מכך, מנוסח החזרה מההסכמה עולה כי הבנייה בפועל היא שהובילה אותם לחזור בהם מהסכמתם. לא מן הנמנע, עם זאת, כי לו הייתה מבוצעת בנייה בהתאם לתכנית ולתשריט, היינו בהתאם להיתר כפי שניתנה לכך ההסכמה מראש, לא היו חוזרים בהם הנתבעים מהסכמתם.

55. במצב דברים זה, הוכח כי בידי אוחריו הסכמה של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

56. כאן המקום לדון בשאלה נוספת והיא לאיזו תוספת או הרחבה ניתנה הסכמת בעלי הדירות. בהקשר זה ניתן ללמוד מנוסח ההסכמה המצוין לעיל כי הסכמת בעלי הדירות ניתנה עבור **"הרחבת הבניה בהתאם לתשריט ולתוכנית שהוצגה בפנינו"** ובאופן פרטני עבור **"הרחבת דירה ובניית מרפסת וגידור החצר"**. הווה אומר כי כל מה שחורג מתשריט ובקשת היתר הבנייה איננו כלול בהסכמת בעלי הדירות וכי ההסכמה רלוונטית אך לבניה בהתאם להיתר הבנייה (נספח יא' לתצהיר הנתבע 1). בהקשר זה יש לדחות את טענת פלאייב כי מדובר ב"הסכמות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תכנוניות שאינן קנייניות". הסכמות להרחבת דירה בהתאם להיתר אינן יכולות להיות "תכנוניות בלבד" כי מובנה בהן שלשם ההרחבה יעשה שימוש גם ברכוש המשותף השייך לכל בעלי הדירות.

57. בפועל, לא בוצעה הבנייה בהתאם להיתר הבנייה באופן מדויק. כך למשל, כפי שראיתי בביקור במקום- דלת הכניסה לדירה מהמרפסת המזרחית נבנתה בצד הקרוב לחלון דירת פלאייב כאשר לפי ההיתר היא אמורה הייתה להיבנות בצד השני. כך גם, חלף חלון שהיה צריך להיבנות לפי היתר הבנייה בנו אוחיון בפועל ויטרינה רחבה המגיעה עד לרצפת המרפסת וחלקה משמש כדלת יציאה (ראה שרטוט המרפסת בהיתר הבניה נספח ה' לתצהיר התובע 1 מיום 18.2.17. כשנשאל על כך בעדותו לא הכחיש זאת הנתבע 1 – ראה פרוט' מיום 1.5.19, עמ' 8-34, עמ' 9 שורה 5).

58. במצב דברים זה הרי שממילא הסכמת בעלי הדירות לא ניתנה לבניית המרפסת כפי שבוצעה בפועל, אלא אך כאמור לבנייה בהתאם להיתר הבנייה.

59. האם נגרמה לדירת פלאייב פגיעה מהותית? ממסכת הראיות, כמו גם מביקורי במקום, לא מצאתי ממש בטענות שהעלה פלאייב בנוגע לחסימת אור ואוויר עקב בניית המרפסת. החלון בדירת פלאייב ממוקם כאמור, מצדה הדרומי של ההרחבה שבוצעה בדירת פלאייב כאשר ממש בסמוך לו, בצדה המזרחי של ההרחבה קיימת ויטרינה גדולה הנפתחת אל החצר וממנה נכנסים אור ואוויר לדירת פלאייב. במצב דברים זה אין בבניית המרפסת, אף אם תפחית את כניסת האור, כדי לגרום לפגיעה מהותית בדירת פלאייב בהיבט עליו של כניסת אור ואוויר והחשכת הדירה. כך גם הטענה לירידת ערך הדירה נטענה בעלמה ולא הוכחה, לא הובאה כל חוות דעת מומחה לתמיכה בטענה זו.

60. עם זאת, בביקור שערכתי במקום ראיתי כי על אף שהמרפסת אינה חוסמת את החלון, קיים אך מרווח צר בין החלון לבין המרפסת, שנבנתה בזווית לכיוון החלון. במצב דברים זה יש בבניית המרפסת באופן בו נבנתה בפועל (כאמור, באופן שאינו תואם את היתר הבנייה) כאשר דלת הכניסה מהמרפסת לדירת אוחיון צמודה לחלון דירת פלאייב, משום פגיעה מהותית בפרטיות של פלאייב, כך שכל העומד במרפסת ונכנס דרכה לדירת אוחיון יכול להשקיף על הנעשה בדירת פלאייב ולראות מבעד לחלון דירתם. כמו כן הבניה בפועל הותירה שאריות של ברזלים בהמשך למרפסת, בסמוך מאוד לחלון דירת פלאייב באופן הפוגע בצורה משמעותית במראה הנשקף מחלון דירת פלאייב (ראה למשל בתמונה האחרונה שצורפה לתצהיר עדותו הראשית של פלאייב). לפיכך, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 71ב(ד) המאפשר למפקח "להורות על ביטול ההחלטה... לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון..." אני מורה כי על אוחיון להתאים את המרפסת באופן מדויק להיתר הבנייה, ובנוסף- בין חלון דירת פלאייב לבין גבול המרפסת הפונה לחלון זה יש להסיר את שאריות הברזל ולהותיר מרווח של שני מטר לפחות בין החלון (היינו בין הקיר החיצוני בו ממוקם החלון) לגבול המרפסת. מרווח כאמור ימנע את הפגיעה המשמעותית בפרטיות דירת פלאייב ויצמצם את הפגיעה החזותית הנשקפת מחלון זה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

61. בהקשר זה אדגיש כי ממילא, כאמור לעיל, הסכמות בעלי הדירות בהן אוחזים אוחיון נכונה אך לבנייה בהתאם להיתר הבנייה. שעה שלא בנו בהתאם לו אין בידיהם הסכמה לבנייה הקיימת בפועל ולפיכך עליהם ממילא להתאים את הבניה להיתר הבניה.

62. יש לדחות את טענת אוחיון כי פלאייב מושתקים מלטעון כנגד המרפסת נוכח קיומה של "הרחבה דומה" בדירתם. לא הוכח כי בדירת פלאייב אכן קיימת "הרחבה דומה" לבניית המרפסת מבחינת אופן ניצול הרכוש המשותף. בדיון שהתקיים ביום 26.6.17 (בעניין צו המניעה) הבהיר עו"ד כהן, ב"כ אוחיון כי הטענה ביחס להרחבה דומה נטענת באשר ל- "כשאני מדבר על הרחבה דומה אני מתייחס גם לחדר בעמודה וגם לחצר המגודרת" (ראה פרוט' 26.6.17 עמ' 8 שורות 10-11). החדר שהוסף לדירת פלאייב אינו דומה למרפסת אותה מבקשים לבנות, שכן באופיין מדובר על הרחבות אחרות, בעיקר בנסיבות המקרה הנדון. לא מצאתי כי ניתן לראות את תוספת השטח לדירת פלאייב כדומה לאותה מרפסת שמבקשים אוחיון לבנו, בעיקר נוכח מיקומה הסמוך לדירת פלאייב. כפי שניתן היה להתרשם מהביקור במקום, וכעולה מהיתר הבנייה אשר צורף כנספח א' לתצהיר פלאייב מיום 5.7.17, מוצג ת/1 הוגש בדיון בצו המניעה - היתר 01/0254.1, כללה התוספת לדירת פלאייב שטח עיקרי לכלל העמודה באמצעות הרחבת הסלון מזרחה וכן ריצוף גינה, בניית פרגולה וגידור. ניתן לראות הרחבה דומה בריצוף החצר וגידורו אשר בוצע בשתי הדירות. עם זאת, אין כל דמיון בין ההרחבה שביצעו פלאייב למרפסת שבנו אוחיון כתוספת לדירתם. על כן, דין הטענה להידחות.

63. לסיום, יש לדחות את טענת אוחיון כי היות שהחלון אינו מצוין בהיתר הבניה הוא נבנה שלא כדין ואין מקום להתחשב בקיומו. כפי שנטען בעדותו של פלאייב- אשר לא הופרכה והייתה מהימנה עלי בהקשר זה- התוספת בעמודה, אשר במסגרתה נבנה גם החלון, התבצעה לפני עשרות שנים (פלאייב רכשו את הדירה בשנת 2004 והוא היה קיים שם עוד שנים קודם לכן- ראה סעיף 10 לתצהיר פלאייב מיום 5.7.17). לא נטען, כל שכן לא הוכח, כי בהיבט הקנייני לא ניתנה בזמנו מראש הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית (סעיף 2 לתקנון המצוי) לפתיחת חלון זה. עקב חלון הזמן, הנטל להוכיח היעדר הסכמה לשינויים ברכוש המשותף מוטל על הטוען לאי החוקיות (ראה בהקשר זה תיק (מפקח ת"א) 6/14 שמאי ואח' נ' טבצ'ניק, [פורסם בנבו] 9.3.14). במקרה הנדון לא נטען במפורש כלל להיעדר הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית לפתיחת חלון, אלא הועלו טענות תכנוניות שמהותן כי לא ניתן לחלון זה היתר בנייה (טענה בתחום דיני התכנון והבניה). ממילא, לא הוכחה הטענה להיעדר הסכמות. ודוק, עניין לנו בשינוי שבוצע ברכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן רשות לשימוש במקרקעין המאפשר לבעלי דירות לחזור מהסכמתם בנסיבות מסוימות (ראה: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127).

64. סיכומי של דבר, בכל הנוגע למרפסת המזרחית, אני מקבלת את התביעה חלקית ומורה לאוחיון להתאים את המרפסת באופן מדויק להיתר הבניה, בכפוף לכך שבין הקיר החיצוני בו ממוקם חלון דירת פלאייב לבין גבול המרפסת הפונה לקיר זה יש להסיר את שאריות הברזל ולהותיר מרווח של שני מטר לפחות בין החלון לגבול המרפסת. על אוחיון לעשות כן בתוך 60 יום מהיום, בפיקוח מהנדס, ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**המחסן**

65. המחסן שנבנה בדירת אוחיון אינו מהווה חלק בלתי נפרד מדירתם. באופן פיסי הוא אינו חלק מדירתם אלא מהווה חדר נפרד הממוקם מתחת למרפסת דירתם. במצב דברים זה הרי שאין מדובר ב"הרחבת דירה" (ראה פרשת עטיה לעיל). אי לכך לא חל סעיף 71ב ויש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות לבניה מסוג זה. הסכמת כל בעלי הדירות לבניית המחסן לא ניתנה ולפיכך על אוחיון להרוס את המחסן ולהשיב שטח זה לרכוש המשותף.

66. אי לכך אני מורה לאוחיון להרוס את המחסן שנבנה מתחת למרפסת המזרחית, להסיר ידם ממנו ולהשיבו לרכוש המשותף (ראה סימון דלת המחסן- נספח ה' לתצהיר התובע 1 מיום 18.2.18), בהתאמה לתשריט הבית המשותף.

**התביעה שכנגד**

**איטום חלון בקיר משותף**

67. מהנימוקים אשר פורטו בסעיף 63 לעיל- דינו של סעד זה להידחות.

**גישה לשטח החצר הסמוכה לדירת פלאייב**

68. אוחיון ביקשו להורות על מעבר בחצר הסמוכה לדירת פלאייב לשם גישה למוני המים והגז, על ידי עובדי הגיחון וחברת הגז וכן ביקשו להסיר את המנעול והקודן מכניסת דלת החצר. היות שלא נטען כי נעשה שימוש שלא כדין בחצר הסמוכה לדירת פלאייב, לא הניחו אוחיון כל תשתית המצדיקה להיעתר לבקשתם להסיר את המנעול והקודן. יש לציין כי אוחיון עצמם, כפי שנראה ברורות בביקור במקום, עושים שימוש ייחודי גם הם בחלק מהחצר המשותפת הסמוכה לדירתם. על כן דינו של סעד זה להידחות.

69. באשר לגישה לשעוני המים והגז הרי שבביקור במקום לא ניתן היה לראות כי קיימים מוני מים וגז משותפים בחצר הסמוכה לדירת פלאייב. מעדותו של הנתבע 1 עלה כי מוני המים והגז של דירת אוחיון כלל לא נמצאים בתחומי חצר זו וכי הנתבעים כיוונו טענותיהם לחסימת גישה למונים של דירות אחרות (ראה פרוט' 1.5.19 עמ' 8 שורות 7-12). בעלי הדירות שנטען כי גישתם נחסמת כלל אינם צד בהליך ולא מצאתי כל יריבות בהקשר זה בין אוחיון לפלאייב. על כן דינו של סעד זה להידחות גם הוא.

**המסד והחללים מתחת לדירת פלאייב**

70. בהקשר זה נטען כי פלאייב פלשו אל קומת המסד והרחיבו דירתם אליה תוך השתלטות על רכוש משותף ובהיעדר הסכמת בעלי הדירות. בביקור במקום ניתן היה לראות (ראה פרוט' ביקור במקום מיום 1.5.19) כי בסמוך למטבח בדירת פלאייב קיימות מדרגות דרכן יורדים לקומה נמוכה יותר. באותה קומה קיים חדר מרוצף עם ארונות (להלן: "החדר") וכן חלל נוסף, הממוקם מתחת למרפסת המזרחית- בצידה הצפוני, שאינו בשימוש, הסגור בבלוקים (להלן: "החלל").



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

71. בכל הנוגע ל"חלל", הרי שמצאתי כי הוא אינו בשימוש של פלאייב, אינו מהווה חלק מדירתם. מדובר בחלל שאינו בשימוש, אינו מסויד או מרוצף, חסום בבלוקים ומלא בפסולת בניה. לפיכך דין הטענה להשגת גבול ביחס לחלל זה- להידחות.

72. בנוגע לחדר בקומת המסד- הרי שהוא אכן משמש כחלק בלתי נפרד מדירת פלאייב (ראה גם פרוט' ביקור במקום מיום 12.12.17 ומיום 1.5.19). באשר לחדר זה טענו פלאייב כי יש ברשותם את הסכמת בעלי הדירות, אולם נספח ד' לתצהיר התובע 1, עליו הסתמכו איננו מלמד כלל על הסכמת בעלי הדירות לבניית חדר בקומת המסד. לכל היותר ניתן ללמוד ממנו על הסכמה לסגירת חלונות שם, וממילא אין בו כדי ללמד על הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש בהתאם לסעיף 71ב לחוק, ביחס להרחבת דירה. בנוסף, פלאייב לא הראו כי מדובר בבנייה שניתן לקבל לגביה היתר לפי תכנית בת תוקף ועל כן כי היא נכללת בהגדרת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71א לחוק. עובדה היא, כי בעוד שפלאייב טרחו וביקשו להכשיר את בנייה שנעשתה ללא היתר בעת שרכשו את דירתם (כמו הרחבת הדירה לעבר החזית המזרחית וריצוף החצר) באמצעות היתר 01/0254.1 (מוצג ת/1), לא עשו כן ביחס לחדר בקומת המסד. אי לכך, ממילא נדרשה להם הסכמת כל בעלי הדירות לשם כך (סעיף 62 לחוק) והסכמה זו אינה בנמצא (וכאמור אף לא הסכמת 3/4 מבעלי הדירות). לא מצאתי בעובדה כי לטענתם בנייה זו נעשתה עוד טרם שרכשו את דירתם בכדי להוריד או להעלות בהקשר זה, שכן כל עוד עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף עליהם להראות כי שימוש זה נעשה בהסכמת בעלי הדירות כדין- וזאת לא עלה בידיהם להראות. ממילא, בנסיבות אלו, לא ניתן לקבל את טענתם ל"הרחבה דומה"- לא ניתן לראות כ- "הרחבה דומה" בניית מחסן שכלל אינו מהווה הרחבה והוספת חדר בקומת מסד אשר גם לגביה לא הוכח שהיא מהווה "הרחבה" כהגדרת מונח זה בסעיף 71א לחוק.

73. יש לדחות גם את טענת פלאייב כי נושא החדר בקומת המסד הוכרע במסגרת ההליך שהתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים (ב"ש 6292/04). מעבר לכך שהכרעת הדין בהליך זה כלל לא הוגשה, הרי שממילא מדובר בהליך פלילי לפי דיני התכנון והבניה בו אין יתר בעלי הדירות צד. לפיכך, אין בהכרעה אליה הפנו פלאייב בכדי להוות מעשה בי דין או כל השתק אחר ביחס להליך דנן, שעניינו בין צדדים אחרים ובעילות שונות מכוח דיני הקניין.

**74. התוצאה היא אפוא כי על פלאייב לסלק ידם מהחדר בקומת המסד, להרוס את המדרגות המובילות לחדר זה מדירתם (בסמוך למטבח דירתם) לסגור את המעבר בין דירתם לקומת המסד ולהותיר את דירתם במפלס אחד בלבד בהתאם לתשריט הבית המשותף ובהתאם לשינויים שהותירו בהיתר הבנייה – 01/0254.1.**

**פינוי חדר המדרגות והמקלט**

75. הטענה כי לפלאייב ציוד בחדר המדרגות ובמקלט שיש להורות על פינויו- לא הוכחה. בביקור במקום לא ראיתי כי יש ציוד כלשהו בחדר המדרגות ואילו במקלט היה קיים ציוד שלא ניתן היה לשייכו דווקא לפלאייב (ראה גם פרוט' ביקור במקום מיום 12.12.17 בהקשר זה). נראה היה שחלק ניכר מבעלי הדירות עושה שימוש במחסן לצורך אחסנת ציוד וממילא לא הוכח שימוש בלתי סביר של פלאייב במקלט או בחדר המדרגות באופן המצדיק להורות על סילוק יד משם.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**ירושלים**

מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסרת מנוע המזגן

76. לא הוכח כי מנוע המזגן חוסם את פתח המילוט באופן בו ניתן לראות בהתקנתו משום שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף. התקנת מנוע מזגן הוכרה זה מכבר כשימוש סביר ברכוש משותף שאין צורך בהסכמת בעלי הדירות לשם התקנתו (ראה: ע"א (ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן** [פורסם ב"נבו"], ניתן ביום 13.1.98, ע"א (י-ם) 2560/01, **נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** [פורסם ב"נבו"], ניתן ביום 4.4.02). לא מצאתי כי נסיבות המקרה דן שונות ומצדיקות לראות בהתקנת מנוע המזגן כשימוש בלתי סביר.

צו מניעה קבוע האוסר על בנייה

77. בקשת אוחיון "ליתן צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבעים, לבצע כל בנייה ברכוש המשותף וכל השתלטות ברכוש המשותף וכן להפריע לשימוש רגיל וסביר של התובעים בכל שטחי הרכוש המשותף" הוא סעד כללי שדינו להידחות משום כך. הבניה הפרטנית עליה הלינו אוחיון נדונה במסגרת פסק הדין ולא מצאתי כל צורך או בסיס ליתן צו כללי כמבוקש. מובן כי על פלאייב (כמו גם אוחיון) לכבד את הוראות הדין ולפעול בהתאם להן ואין צורך בצו אשר יורה על כך, מעבר לאלו הפרטניים אשר ניתנו במסגרת פסק הדין.

1. סוף דבר

78. התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה-

79. על אוחיון להתאים את המרפסת באופן מדויק להיתר הבנייה (כך למשל ביחס למיקום הדלת, מיקום החלונות), כאשר בין הקיר החיצוני בו ממוקם חלון דירת פלאייב לבין גבול המרפסת הפונה לחלון זה יש להסיר את שאריות הברזל ולהותיר מרווח של שני מטר לפחות. על אוחיון לעשות כן בתוך 60 יום מהיום, בפיקוח מהנדס, ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

80. על אוחיון להרוס את המחסן שנבנה מתחת למרפסת המזרחית, להסיר ידם ממנו ולהשיבו לרכוש המשותף (ראה סימון דלת המחסן- נספח ה' לתצהיר התובע 1 מיום 18.2.18), בהתאמה לתשריט הבית המשותף. על אוחיון לעשות כן בתוך 60 יום מהיום, בפיקוח מהנדס, ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

81. התביעה שכנגד מתקבלת אף היא בחלקה- על פלאייב לסלק ידם מהחדר בקומת המסד, להרוס את המדרגות המובילות לחדר זה מדירתם (בסמוך למטבח דירתם) לסגור את המעבר בין דירתם לקומת המסד ולהותיר את דירתם במפלס אחד בלבד בהתאם לתשריט הבית המשותף ובהתאם לשינויים שהותרו בהיתר הבנייה – 01/0254.1. על פלאייב לעשות כן בתוך 60 יום מהיום, בפיקוח מהנדס ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

82. יתר הסעדים בתביעה שכנגד- נדחים.

83. בשים לב לתוצאת ההליך, יישא כל צד בהוצאותיו.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/241/2017, 1/357/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן היום, י"ח כסלו תש"פ, 16 דצמבר 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין